

第31問

甲は、実母であるA（72歳）が認知症となり、体も不自由となっていたため、一人暮らしの自宅に引き取って身の回りの世話をしていた。

甲がAを引き取ってから約1年が経過したある日、甲の友人である乙は、日々、憔悴していく甲に対して、「仕事をしながらAの世話をするのは大変だろう。俺も手伝うから、どこかに放置してきてはどうか。」などと告げた。甲は、Aの介護に疲弊しきっていたため、乙の提案に従うことにした。

甲及び乙は、3月10日午前2時頃、眠っているAを自動車に乗せて、郊外にある森林公園の入口に放置して立ち去った。このとき、乙は、Aが死亡してもかまわないと思っていたが、甲は、朝になったら、森林公園の職員がAを発見するから、死亡することはないだろうと思っていた。

森林公園の入口は、普段は、ほとんど人通りのない場所であったが、同日午前4時頃、たまたま丙が近くを自動車を通りかかり、Aの存在を認めた。しかし、丙は、面倒なことに巻き込まれたくないと思い、何もすることなく、その場を離れた。

その後、Aは、朝10時頃に森林公園の職員に発見され病院に搬送された。Aは重度の低体温症に起因する呼吸障害に罹患していたが、2週間後に回復した。

甲、乙及び丙の罪責について、論じなさい。

（北海道大学法科大学院 平成26年度 改題）

第1 甲の罪責について

実母であるAを森林公園の入口に放置して立ち去った行為について、保護責任者遺棄致傷罪（219）の成立可能性がある。なお、作為形態が218条の「遺棄」に含まれることには学説上争いがない。

一方で、甲には殺意がないから殺人罪は成立しない。

本問では、甲はAの実子であること、Aが認知症になり、体も不自由であることから、「保護」「責任」が認められ、Aを普段ほとんど人通りのない森林公園の入口に「遺棄」（移置）し、重度の低体温症に起因する呼吸障害という「傷」害を与えているため、同罪が成立する。

第2 乙の罪責

- 1 乙には殺意があるから、殺人未遂罪を検討すればよい。
- 2 甲との共犯関係については、最決平17.7.4【百選16】が殺人と保護責任者遺棄致死罪の場合に「保護責任者遺棄致死罪の限度で共同正犯となる」とする。部分的犯罪共同説になじむ判示とされるなどと評されているが、異論もあるところである。

ただし、この事案は、不作為形態による殺人が問題となったものである。本問は作為形態による殺人が問題となる事案であるから、本問において「保護責任者遺棄致死罪の限度で共同正犯となる」か否かは不明である。乙には、作為義務（判例・通説によれば、保護責任と同義）が認められないことを重視すれば、遺棄致傷罪の限度でのみ重なり合いが認められ、共同正犯となるにすぎないだろう。

いずれにしても、共同正犯と錯誤の問題を論じる必要がある（**論点** 共犯と錯誤～共同正犯（共同正犯の本質論）  司H20,H29,R3,旧H5-1,H11-1,H18-1,H20-1）。なお、実行行為たる遺棄（移置）を共同している以上、乙に成立する共犯形態は、当然共同正犯である（いわゆる実行共同正犯）。

 総合 154 頁  論証 63 頁

第3 丙の罪責

- 1 丙はたまたま近くを自動車で通りかかり、Aの存在を認めながらも、これを置き去りにしているから、単純遺棄罪又は保護責任者遺棄罪の成立が考えられる。
- 2 この点について、作為義務＝保護責任であるとする判例・通説を前提とすると、たまたま通りかかっただけの丙に保護責任を認めることはできず、単純遺棄罪の成否が問題になるにすぎない。もっとも、丙は、置き去りにしているにすぎず、217条の「遺棄」には当たらない（最判昭34.7.24参照）（**論点** 「遺棄」（217等）の意義）。
- 3 以上より、丙は不可罰である。

 総合 173 頁  論証 71 頁

答案構成

第1 甲の罪責

- 1 保護責任者遺棄致傷罪（218、219）
↓
- 2 保護責任者遺棄罪の要件検討
↓
- 3 傷害結果発生
↓
加重結果に対する過失は不要
↓
- 4 保護責任者遺棄致傷罪が成立し、遺棄致傷罪の限度で乙と共同正犯となる（60）

第2 乙の罪責

- 1 殺人未遂罪（203、199）の成立
↓
- 2 共同正犯の成立範囲
↓
部分的犯罪共同説
↓
遺棄致傷罪の限度で、共同正犯となる
↓
- 3 乙には殺人未遂罪が成立し、遺棄致傷罪の限度で甲と共同正犯になる

第3 丙の罪責

- 1 保護責任者遺棄致傷罪不成立
↓
- 2 遺棄致傷罪の成否
↓
「遺棄」の意義
↓
作為形態の移置のみ
↓
あてはめ
↓
- 3 丙は不可罰

第1 甲の罪責

1 甲が、Aを郊外にある森林公園の入口に放置して立ち去った行為について、保護責任者遺棄致傷罪（218条、219条）の成立が考えられる。なお、甲は、Aが死ぬとは考えていなかったのであり、殺意が認められないから、甲に殺人未遂罪は成立しない。

2 Aは、72歳と高齢で、認知症であり、体も不自由となっているから、「扶助を必要とする」（217条参照）者として、「老年者」に当たる。

そして、甲は、Aの子であり、扶養義務を負っている（民法877条1項）ところ、Aを自宅に引き取って、身の回りの世話をしていたのであり、Aと社会継続的保護関係があったといえる。さらに、Aは上記のように扶助を必要とする状態であり、甲が一人暮らしの自宅で世話をしていたのであるから、Aの身体生命の安全について甲に排他的に依存していたといえる。よって、甲にはAの生命身体に対する保護義務が認められ、「保護する責任のある者」に当たる。

また、甲は、乙と共に、Aを自動車で森林公園の入口という人通りが少ない場所に、午前2時という人がほとんど通らない時間帯に放置しており、移置しているから、「遺棄」したといえる。

3 さらに、Aは、重度の低体温症に起因する呼吸障害に罹患しており、生理的機能に障害が生じたといえるため、人を「傷」害したといえる。

なお、基本犯たる実行行為に加重的結果が発生する危険性が内包され

1

ているといえるため、結果的加重犯の成立には過失は不要であると考えられる。

4 以上より、保護責任者遺棄致傷罪が成立し、甲は、その罪責を負う。なお、後述のように、遺棄致傷罪の限度で乙と共同正犯となる（60条）。

第2 乙の罪責

1 乙が、Aが死亡してもかまわないとして殺意を抱き、甲と共に、Aを森林公園の入口に放置して立ち去った行為は、殺人罪の実行行為に該当する。

もっとも、Aは職員によって保護され、死亡していないため、未遂罪が成立するととどまる（203条、199条）。

2 乙は、遺棄行為を甲と共同しているから、甲と共同正犯となることと考えられるが、上記のように、甲と乙に成立する罪名は異なる。では、このような場合も「共同して犯罪を実行した」として共同正犯となるか。

相互利用補充関係に基づく共同犯行の一体性という共同正犯の性質からすれば、共同正犯が成立するためには、共同して特定の構成要件を実現したという事実を要するというべきである。すなわち、「犯罪」とは特定の構成要件の実現を意味すると解すべきである。そうすると、共同正犯間の故意が異なる場合、共同正犯が成立しないかにもみえる。

しかし、構成要件的に重なり合う範囲については「犯罪」の「共同」が認められる。

2

したがって、そのような限度で共同正犯の成立が認められるというべきである。

保護責任者遺棄致傷罪と殺人未遂罪は、両罪とも保護法益が被害者の生命（身体）であり、また、遺棄（移置）という行為態様も共通する。もっとも、乙には保護責任が認められないから、遺棄致傷罪（217条、219条）の限度で、実質的な重なり合いを認めることができる。

以上より、甲と乙は遺棄致傷罪の限度で、共同正犯としての罪責を負う。

3 よって、乙には殺人未遂罪が成立し、遺棄致傷罪の限度で甲と共同正犯になる。

第3 丙の罪責

1 丙がAの存在を見つけたにもかかわらず、何もせずその場を離れた行為について、保護責任者遺棄致傷罪が成立するかが問題となるも、否定すべきであると考ええる。

なぜなら、丙には、先行行為や排他的支配の設定はなく、保護責任（作為義務）が認められないためである。

2 では、丙に遺棄致傷罪が成立するか。丙は置き去りを行っているにすぎないところ、これが217条にいう「遺棄」に該当するか否かが問題となる。

(1) 217条は保護責任のない者を処罰する規定であるから、そのような者に不作為を処罰するための作為義務は認められない。

したがって、217条の遺棄は作為形態である移置のみを指すもの

3

と考える。

(2) 丙は置き去りを行っているにすぎない以上、「遺棄」したとはいえない。

3 以上より、丙は何らの罪責を負わない。

以上

4